

1508837-68.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... já que tais condutas (uso e tráfico) frequentemente coexistem. A esse respeito, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot\\_tjsp\\_jus\\_br/](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/ERcxrFGG5apMsl0ywWpwFvcBzAXTQUCJMMiDuPlz6P4zMA?e=sRPu56)

ERcxrFGG5apMsl0ywWpwFvcBzAXTQUCJMMiDuPlz6P4zMA?e=sRPu56

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1508837-68.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000999

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190120/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 26119099 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2190120 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MANOEL DO NASCIMENTO

Em 13 de outubro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Dalva Maria Edwiges Ferreira Werlang OAB 478128/SP, Advogada, ora defendendo o acusado RODRIGO MANOEL DO NASCIMENTO; o acusado referido; e as testemunhas Estevam Luiz de Oliveira, Aguinaldo Aparecido Pesuto e Diego Aparecido Almeida Cornachin, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. O ato teve que ser repetido, em virtude de problema na gravação. Ao final, a Defensora Requereu a realização de exame de dependência toxicológica, bem como a revogação da prisão preventiva do réu, que foram afastados, conforme gravação. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. RODRIGO MANOEL DO NASCIMENTO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (p. 155-157). A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2022 (p. 161-162) e o réu foi citado (p. 202). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o

Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico-toxicológico. A autoria é certa. Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva e alegou, em suma, que está sendo falsamente incriminado, pois não havia nenhuma droga em seu veículo, que sequer foi revistado. Os policiais militares Diego e Agnaldo relataram, em linhas gerais, que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu e Estevam, ambos conhecidos pelo tráfico, conversando em frente à residência do último. Procederam à abordagem de ambos e nada de ilícito foi encontrado. Estevam disse que tinha um compromisso e foi liberado. O veículo do réu estava nas proximidades e ele confirmou a propriedade do automóvel, em relação ao qual havia notícias de que era utilizado no comércio espúrio. No interior de uma mochila que estava no carro foi encontrado, além de marmita e outros pertences do réu, meio quilo de "crack". Ele negou a propriedade do entorpecente. A testemunha Estevam disse que estava conversando com o réu em frente à sua residência quando foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado, então foi liberado e não acompanhou a revista no veículo do acusado. Após os fatos, tomou conhecimento, pela ex-esposa do réu, que ele era "perseguido" pelo policial Aguinaldo. Não pratica o tráfico e o local não era conhecido por esse motivo. Conforme se vê, a negativa do réu foi rechaçada pelas provas colhidas. Os policiais apresentaram depoimentos coesos a respeito dos fatos e da localização de drogas em uma mochila encontrada no interior do veículo do acusado. Nada há nos autos a embasar a alegação de falsa incriminação e não se vislumbra motivo capaz de colocar em xeque tais depoimentos, tampouco foi aventado qualquer motivo concreto para que desejassem incriminar falsamente o acusado. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). No mais, os o relato dos policiais, notadamente Aguinaldo, é suficiente para justificar a fundada suspeita motivadora da abordagem, tanto que houve o encontro das drogas no carro do réu, o que afasta a alegação defensiva de nulidade. Sobre o tema, vale citar trecho de decisão proferida pela E. 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: "E se não lhes permitirmos que abordem quem lhes parecer suspeito por adoção de atitudes que lhes são reveladoras de suspeição em razão da rica experiência adquirida (pressuposições empiricamente justificadas), fatalmente vamos lhes castrar a efetividade no enfrentamento à criminalidade, que grassa cada vez mais desinibida. (...). Logo, é indevido esperar que o policial seja ingênuo na identificação de certa conduta, por ele já visualizada em outras situações de tráfico, como denotadora de suspeição, pelo contrário, é louvável que tenha ganho, com a experiência, aludida expertise, a mesma que se verifica, por exemplo, quanto aos agentes policiais e alfandegários nos aeroportos quando elegem pessoas à revista por meio de leitura corporal que passa despercebida por gente comum" (Ap. Crim. 1500559- 92.2021.826.0535, julgada em 08.08.2022). Veja-se, ainda, excerto de acórdão proferido pela E. 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: Com efeito, a palavra dos policiais, assim como vale para dar atestado do que presenciaram e do que apreenderam com o acusado, vale para justificar a abordagem e a fundada suspeita, cuja prova decorre menos do quanto disseram e mais do que efetivamente encontraram. Ou seja, não há maior atestado de que a suspeita era fundada do que o encontro da droga com o sujeito alvo da busca pessoal e a consequente prisão em

flagrante. (Apelação Criminal nº 1500428-11.2022.8.26.0559, julgada em 12/09/2002). E ainda que o réu também seja usuário, tal fato não afastaria o crime em comento, já que tais condutas (uso e tráfico) frequentemente coexistem. A esse respeito, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)." Não há, pois, como acolher as teses defensivas, pois o crime narrado na denúncia foi suficientemente comprovado. Procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Na primeira fase, verifico que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade e a alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Ademais, noto que o réu ostenta maus antecedentes, justamente em virtude da prática de tráfico (certidão de fls. 119/120 - Proc. nº 0001602-18.2008). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme se vislumbra de fls. 120/121 (Processo nº 0004867-76.2018), majoro a pena de 1/6 para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. Inaplicável o benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente e possui maus antecedentes. Assim, considerando a pena aplicada, a reincidência do acusado e seus maus antecedentes, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, CP. A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à míngua de elementos que denotem condição financeira que permita a majoração. Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III,

alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu RODRIGO MANOEL DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. O réu não poderá apelar em liberdade, pois permanecem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e a Defensora informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_(Caio C. T. Mazziero), digitei.

## TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: RODRIGO MANOEL DO NASCIMENTO

RG: 45480171, RJI: 203584475-26

Data De Nascimento: 16/03/1986

Filiação: pai JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO, mãe RUTH FLORINDO DO NASCIMENTO

Residência: Rua Joaquina Maria Madalena, 10, Jardim Joao Ballan, RUA JOAQUINA MARIA MADALENA - CEP 17212-032, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.